

1500547-08.2022.8.26.0062

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... firme a demonstrar que o réu realizava tráfico de drogas no local dos fatos, comercializando, no local da apreensão, a cocaína, cuja posse assumiu judicialmente.

No mais, as testemunhas foram firmes, seguras e coerentes ao apontarem a dinâmica da abordagem. Note-se terem as testemunhas esclarecido que o réu, em local tido como ponto de tráfico; já conhecido dos meios ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500547-08.2022.8.26.0062 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500547-08.2022.8.26.0062

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2024728/2022 - DEL.POL.BARIRI, 22679379 - DEL.POL.BARIRI, 127/22/202 - DEL.POL.BARIRI, 2024728 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO FRANCISCO RANGEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

LEONARDO FRANCISCO RANGEL foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta de 15h10min, na Av. Dr. Antônio Galízia, 1445, Núcleo Osório Orefice, nesta cidade e comarca de Bariri-SP, guardava, sem autorização legal e para fins de tráfico, 8,02 (oito gramas e dois decigramas) de cocaína, acondicionada em 19 (dezenove) microtubos plásticos do tipo eppendorff.

Defesa prévia às fls. 100/102.

Às fls. 135/136, foi recebida a denúncia.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e, ao

final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas, às fls. 161/168, e, sustentando estar provada a materialidade e autoria, requereu a condenação do réu. Requereu o afastamento do privilégio do art. 33, §4º, da LD e a, ainda, a fixação do regime fechado.

A Defesa, por sua vez, nas alegações finais de fls. 170/173, requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da LD; subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; a fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito se encontra formalmente em ordem, de modo que, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, não havendo, ainda, nulidade a sanar, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A existência do fato (materialidade) está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05); auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); laudo pericial de fls. 121/125; e, ainda, pela prova coligida em Juízo.

Passo, pois, ao exame da autoria.

Com relação à autoria, o réu, em seu interrogatório, declarou que, quando menor, foi internado na Fundação Casa por ato infracional análogo ao de tráfico. Declarou ser verdade que ali estava traficando. Perguntado sobre há quanto tempo estava traficando, declarou que “pouco”, atuava “um dia por semana”. Da data da abordagem, estava traficando há menos de um mês, “não ficava lá muito”. Antes disso, estava trabalhando. É usuário de drogas, usa cocaína e “maconha”. No dia da abordagem, estava com cocaína. Falou aos policiais que a droga não era sua e não disse que é usuário. Não tem bens próprios. Foi internado na fundação, e, depois, passou a trabalhar. Sustentava seu vício com esse dinheiro. A droga que foi apreendida era sua. Confirma o relato dos policiais, de que a droga era destinada à venda. Confrontando a confissão com os demais elementos de prova, analisados em conjunto (arts. 197 e 200 do CPP), noto que a autoria do delito do art. 33, caput, da LD, foi suficientemente demonstrada, com a elucidação da dinâmica dos eventos pela prova oral.

A testemunha Claudionor José da Silva declarou que se recordar da ocorrência. Na data dos fatos, estavam em patrulhamento preventivo. O local é bastante conhecido como ponto de tráfico de drogas, ali sendo realizados diversos flagrantes. Nessa ocasião, visualizaram o réu Leonardo ao lado de uma igreja. Leonardo estava abaixado, próximo a um gramado. Quando visualizou a viatura, deu alguns passos para trás e sentou, tentando “disfarçar”. O que motivou a abordagem foi tal comportamento. Ainda, tinham conhecimento de que o réu já tinha sido apreendido pelo mesmo crime. Leonardo era conhecido dos meios policiais. Feita a busca pessoal, foram localizados R\$ 24,00. O policial Avoleta, efetuando uma varredura naquela localidade, onde estava Leonardo, encontrou saquinhos de pipoca vazios e um saquinho com 19 porções de cocaína. Leonardo negou a posse da droga e foi conduzido à Delegacia. Leonardo já tinha sido visto, anteriormente, na mesma biqueira. Leonardo estava sozinho. Da rua até o local onde o réu estava, havia no máximo 15 metros, e, do local onde foi encontrada a droga, havia no máximo 1,5 m. Na data dos fatos, apenas o réu ali estava, porém, em outras datas, outras pessoas já foram presas naquele local.

A testemunha Antônio Avoleta Neto, policial militar, em síntese, prestou depoimento no mesmo sentido da testemunha Claudionor. A equipe já tinha conhecimento de que ali era ponto de tráfico de drogas. Lá chegando, visualizou Leonardo sendo abordado pelos policiais Silva e Devair, que aguardavam apoio policial. “Vasculhando” no

gramado, terminada a calçada que margeia o gramado, entre o concreto e a grama, encontrou dois invólucros de plástico transparente, contendo, em seu interior, a cocaína apreendida. Também foram encontrados invólucros vazios. Leonardo disse que a droga não era dele, e ali estava para utilizar maconha. Não encontraram “cigarro de maconha” e as mãos de Leonardo não tinha tal odor. Já o conhecia do bairro e já o tinha visto naquela esquina. Tem conhecimento de que Leonardo já foi preso, anteriormente, por tráfico de entorpecentes. Não participou do início da abordagem. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, porquanto são testemunhas compromissadas assim como as demais, inexistente razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de seus relatos.

Nesse sentido, o TJSP: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Ademais, inexistente nos autos prova de que tivessem a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime não cometido.

Como se nota, a prova amealhada nos autos é firme a demonstrar que o réu realizava tráfico de drogas no local dos fatos, comercializando, no local da apreensão, a cocaína, cuja posse assumiu judicialmente.

No mais, as testemunhas foram firmes, seguras e coerentes ao apontarem a dinâmica da abordagem. Note-se terem as testemunhas esclarecido que o réu, em local tido como ponto de tráfico; já conhecido dos meios policiais (ante sua apreensão anterior – veja-se ter o réu informado a prática de ato infracional equiparado ao tráfico, enquanto menor); ao avistá-las, adotou comportamento dissimulado (pois estava abaixado, próximo a um gramado, e, ao visualizar a viatura, deu alguns passos para trás e sentou, tentando “disfarçar”), circunstâncias externas, objetivas e concretas compreendidas nas fundadas razões do art. 240 do CPP.

Assim, diante de todo o conjunto probatório, suficiente concluir que o réu, de fato, trazia consigo os entorpecentes e foi abordado em situação de flagrante (art. 302 do CPP), não se cogitando de aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Noutro vértice, conforme preceitua o art. 28, §2º, da Lei de Drogas, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, há de se atentar à: a) natureza e quantidade da substância apreendida; b) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação; c) às circunstâncias sociais e pessoais; bem como e) à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em concreto, o próprio réu confessou que as drogas eram destinadas à venda. Demais disso, os entorpecentes estavam acondicionados de forma usual à venda, em 19 (dezenove) microtubos plásticos do tipo eppendorff (auto de exibição de fls. 15/16).

Ademais, o tráfico de drogas, na modalidade “guardar”, prescinde da prova da mercancia (Jurisprudência em teses, STJ – Edição 131), bastando a demonstração de tal finalidade, cabalmente comprovada nos autos.

Além disso, é firme o entendimento de que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, bastando, para a incursão no crime de tráfico, que o agente incorra em qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, como ocorreu no caso. Portanto, não cogito a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, afastando tal tese de Defesa.

Portanto, presentes a materialidade e a prova segura da autoria, cumpre examinar as questões relativas à tipicidade penal.

O réu era menor de 21 anos à data dos fatos (fl. 33), e, ainda, confessou, razão pela qual as respectivas atenuantes serão oportunamente examinadas.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o dispositivo prevê: “§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”.

No caso em tela, o réu é primário (fl. 33).

Nessa toada, consoante definido pelo STF, 2ª Turma, no HC 154.694/SP, para fins do art. 33, §3º, da Lei de Drogas, milita em favor do réu a presunção de que é primário, possui bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus de provar o contrário é do Ministério Público, do qual não se desincumbiu a contento.

Não se olvida que, consoante certidão de fls. 34, durante a menoridade, Leonardo cometeu ato infracional equiparado exatamente ao tráfico de drogas, o que resultou na medida socioeducativa imposta nos autos de nº 1500489-44.2018.8.26.0062.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021, para fins de consolidação jurisprudencial, pacificou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, desde que apontada a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

No caso dos autos, o ato infracional foi praticado em 2018.

Assim, na esteira da jurisprudência do STJ, o longo transcurso de tempo entre aquele e o crime em análise (praticado em 2022) afasta a idoneidade de tal fundamento como prova de dedicação à atividade criminosa.

Quanto ao mais, inexistem elementos concretos a demonstrar a presença de um dos elementos que impedem a aplicação da causa de diminuição.

Ante o exposto, suficientemente comprovadas a existência e a autoria do fato descrito na denúncia, e não se verificando a ocorrência de causa ou circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, é peremptória a responsabilização penal do réu.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, art. 42 da Lei 11.343 e arts. 59 e 68, do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

Na primeira fase, convém rememorar o art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Em atenção às circunstâncias do caso em tela, não é o caso aplicar a sanção-base acima do mínimo legal pelo fato de a droga apreendida ser “cocaína”.

Consoante entendimento do TJSP, “(...) a natureza da substância (cocaína), por si, não impõe, necessária e automaticamente, o aumento da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.”

(TJSP; Apelação Criminal 1501716-98.2019.8.26.0526; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/01/2021; Data de Registro: 26/01/2021).

Assim, e tendo em vista que os requisitos do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade) são cumulativos (STJ, HC Nº 567.261 – RJ, - DJe: 16/06/2020), a quantidade e a natureza da droga apreendida, no caso destes autos, não justificam o aumento da pena.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos.

O réu não possui maus antecedentes.

Os motivos que o levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As consequências foram normais.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

Não há falar em comportamento da vítima em tal espécie de delito (crime vago).

Logo, fixo, na primeira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo, embora presentes as atenuantes do art. 65, inciso I e III, alínea "d", do CP, incabível a redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Logo, estabilizo a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento.

Por outro lado, cabível a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

A redução se impõe no máximo patamar, isto é, 2/3, não se visualizando circunstâncias excepcionais que imponham a modulação do redutor em parâmetro mais prejudicial.

Observo que, em caso semelhante, o TJSP considerou que, se a quantidade de droga não for expressiva (como aqui ocorre), a natureza da droga (cocaína) não autoriza a escolha de fração mais prejudicial ao réu na modulação da causa de diminuição.

Nesse sentido: "(...) considerando que a quantidade da droga apreendida não é expressiva, tão-só a natureza da droga (cocaína) não serve para justificar uma redução diferenciada, considerando ainda que as demais circunstâncias judiciais são favoráveis. Dessa forma, cabível a redução máxima (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500787-45.2018.8.26.0544; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021).

Portanto, diminuo a pena em 2/3 e a fixo, definitivamente, em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Regime inicial

Para a fixação do regime inicial, cumpre observar os critérios do art. 33, §§2º e 3º e art. 59, todos do Código Penal.

No caso dos autos, o réu é primário e não há adequação na fixação de regime inicial mais gravoso, mormente ante o quantum da pena.

Estabeleço, pois, o regime inicial ABERTO, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal

Não há falar em aplicação da regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal (detração penal) neste momento, porquanto o benefício não se confunde com progressão de regime; e, ainda, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento sedimentado da jurisprudência do STJ (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

De início, saliento que, no julgamento do HC 97.256, o Tribunal Pleno do STF, por maioria, considerou inconstitucionais os dispositivos da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) que vedam a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Posto isso, o réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, segunda parte, e §4º, do CP), consistentes em:

a) prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (art. 46, §4º, do CP); e, b) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo (art. 45, §1º, do CP), em

favor de entidade pública ou privada com destinação social, conforme definir o Juízo das Execuções Criminais.
Diante da substituição, resulta prejudicada a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Indenização mínima

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conforme art. 387 do CPP, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LEONARDO FRANCISCO RANGEL, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 08 meses reclusão; e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal; substituída, a pena corporal, por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (art. 46, §4º, do CP); e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo (art. 45, §1º, do CP), em favor de entidade pública ou privada com destinação social, conforme definir o Juízo das Execuções Criminais.
Na hipótese de descumprimento injustificado (art. 44, § 4º do Código Penal), deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime ABERTO (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

"Status Libertatis": Em razão da pena aplicada e substituída, não estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Logo, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Disposições finais

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Transitada em julgado:

- a) Expeçam-se as guias de execução definitiva;
 - b) Proceda-se à atualização do valor da multa, intimando-se o réu para pagamento em 10 dias, nos termos dos arts. 49, §2º, 50 e 51 do CP e 164 da LEP;
 - c) Oficie-se ao IIRGD;
 - d) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.
- Expeça-se a certidão ao Defensor Dativo, se o caso, conforme valores e termos do Convênio OAB/Defensoria.
Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do CPP).
Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Bariri, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA